

1501400-81.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... no país para a prática do crime de tráfico, não podendo, portanto, ser considerada para o fim de agravar a pena. Veja-se a respeito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501400-81.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501400-81.2021.8.26.0537 2021/001162

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS

Juíza de Direito: Dra. CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

LEONARDO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS, qualificado a fl. 25, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 16h30min, na Passagem do Progresso, número 219, bairro Vila Nogueira, nesta cidade e Comarca de Diadema, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 25 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 20,91 gramas, 35 invólucros plásticos contendo crack, com peso aproximado de 08 gramas e 30 invólucros plásticos contendo maconha, com peso aproximado de 62,77 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de covid-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, proferiu-se decisão convertendo a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (fls. 78/80). Mandado de prisão expedido às fls. 82 e devidamente cumprido às fls. 136.

Notificado (fl. 129), o réu apresentou defesa prévia às fls. 141/150 e a denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2021 (fls. 151/152), mesma ocasião em que foi mantida a prisão preventiva dele.

O réu foi citado (fl. 196), e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia de hoje, a qual se realizou de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 e resolução 329/2020 do Conselho Nacional de

Justiça, ocasião em que foram as duas testemunhas policiais arroladas, bem como interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre a acusação e a defesa.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia, posto que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente demonstradas. Aponta que a versão apresentada pelo acusado em Juízo está isolada dos demais elementos de prova colhidos, e é inverossímil. Já a versão apresentada pelos policiais está em harmonia com a versão por ele apresentada em sede policial, e eles não tinham qualquer interesse em prejudicar o acusado. Aponta que o réu possui maus antecedentes, é reincidente, e que a atenuante da confissão espontânea não deve ser reconhecida, mas não se opõe seja reconhecida a confissão extrajudicial, se este Juízo entender seja o caso. Entende não ser cabível a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da lei 11.343/06. Pede fixação do regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do acervo probatório. Aponta que o depoimento dos policiais foram vagos e genéricos, e que não são isentos para servir como elemento de prova. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/06 e em caso de condenação, pede a fixação da pena base no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda etapa, pede seja afastada a agravante de que trata o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, posto que a pandemia em nada contribuiu para a prática do crime. Pleiteia ainda a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, computando-se no tempo da pena a ser fixada o período de tempo em que o réu permaneceu custodiado por este processo, para fins do quanto disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias (fls. 17/20), laudo de constatação (fls. 21/23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 170/172), e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Em sede policial, o réu confessou a autoria delitativa, narrando " que estava no local comercializando drogas, bem como afirmou ser seu primeiro dia nesta atividade, informou, ainda que iria receber 15% das vendas das drogas. Com relação a importância de R\$ 50,00 reais em notas trocas declarou ser proveniente da traficância." (fls. 09)

Já interrogado em Juízo, o réu negou a autoria dos fatos, relatando que estava na rua, em Diadema, para comprar entorpecentes e falou com um indivíduo, que pediu que aguardasse e foi embora. Havia saído da cadeia há pouco tempo. Aguardou por cerca de 20 ou 25 minutos no local e foi abordado, e explicou que o dinheiro que possuía era para comprar as drogas e voltar para casa, em São Bernardo do Campo. Os policiais então localizaram a bolsa com as drogas e o levaram para a Delegacia. Em nenhum momento confessou na Delegacia a prática do crime, e que apenas havia ido até o local dos fatos para comprar as drogas por saber que a qualidade dos entorpecentes era melhor. Disse que foi até o local dos fatos de ônibus. Seu irmão possui um bar e deu dinheiro para que ele procurasse trabalho, não para que comprasse drogas. Não conhece os policiais que o prenderam.

Tal versão, entretanto, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Cleber Matias de Oliveira, policial civil, afirmou que receberam a denúncia anônima que um indivíduo com certas características e vestimentas estaria traficando no

local dos fatos. Dirigiu-se até o local dos fatos com sua parceira Ana Cláudia, onde o réu foi abordado e confessou a prática do crime. Ele trazia R\$ 50,00, produto da traficância, no bolso da calça. Foi levado à Delegacia, onde disse que ganharia cerca de 15% do total das vendas. O réu havia escondido os entorpecentes cerca de 05 metros do local da abordagem, atrás de um portão de ferro em uma residência, na Viela Tião Carreiro. Com o acusado foram encontradas cerca de 30 de cada tipo de droga - crack, cocaína e maconha. Na delegacia o réu admitiu que estava traficando. Quando chegaram, viram o réu estava parado, sozinho, e não havia ninguém próximo a ele.

No mesmo sentido, a testemunha Ana Cláudia de Barros Dias, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que foram apurar denúncia anônima referente a indivíduo com as mesmas características do réu. Quando chegaram até o local indicado na denúncia, visualizaram o acusado com as mesmas características e vestimentas, e o abordaram, e com ele encontraram dinheiro. Ele disse que o valor era fruto de tráfico, era o primeiro dia dele, e indicou onde estava a bolsa onde estavam armazenadas as drogas. Após, foi conduzido a Delegacia. A bolsa estava a cerca de 10 metros do local onde o réu foi abordado, em um portão em uma residência de ferro na Passagem Tião Carreiro. Não conhecia o réu antes dos fatos. O valor apreendido com o acusado era de R\$ 50,00, segundo se lembra. As drogas encontradas eram porções de maconha, crack e cocaína. Por ocasião da abordagem, havia apenas o réu no local, não se recorda de haver ninguém próximo.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada e, por outro lado, a versão do réu não veio acompanhada de qualquer suporte probatório. Dessa forma, verifica-se que as testemunhas policiais receberam denúncia anônima dando conta de que um indivíduo estaria traficando no local dos fatos, para onde se dirigiram e avistaram o acusado, com as mesmas características descritas na denúncia, razão pela qual optaram por abordá-lo. Com o réu, foi encontrada a quantia de R\$ 50,00 em espécie, tendo ele confessado informalmente estava traficando, no momento da abordagem pelos policiais. O réu também indicou que nas proximidades, em cerca de 10 metros do local da abordagem, estava a bolsa na qual foram localizados os entorpecentes apreendidos nestes autos, a saber, os 25 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 20,91 gramas, 35 invólucros plásticos contendo crack, com peso aproximado de 08 gramas e 30 invólucros plásticos contendo maconha, com peso aproximado de 62,77 gramas. Tais circunstâncias evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cabe ressaltar que a condição de viciado do réu não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a prática do crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício. Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que

se tratasse de substância para consumo pessoal.

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 48/54 e 124/126 - as condenações nos processos 0000718-79.2016.8.26.0537 e 0015847-14.2014.8.26.0564 serão consideradas para fins de reincidência). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da dupla reincidência (fls. 48/54 e 124/126 - processo nº 0000718-79.2016.8.26.0537 e 0015847-

14.2014.8.26.0564), compensando uma delas com a confissão extrajudicial. Assim, aumento a pena apenas em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Consigno que em nenhum momento a ação do acusado foi favorecida pela situação de calamidade pública atualmente vivenciada no país para a prática do crime de tráfico, não podendo, portanto, ser considerada para o fim de agravar a pena. Veja-se a respeito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados." (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 07/06/2021)

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Logo, não preenche o requisito previsto no mencionado dispositivo legal para a concessão desse benefício. Assim, as penas ficam mantidas, em caráter definitivo, nos patamares obtidos nas fases anteriores da dosimetria.

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime FECHADO, o qual se justifica, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente, e em razão da variedade de drogas, circunstâncias preponderantes nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável. Pelas mesmas razões, mostra-se impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 e seguintes do Código penal.

Impossível, ainda, aplicar disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO LEONARDO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no artigo 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 78/80) já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Com relação à quantia de R\$ 50,00 apreendida (fls. 14/15 e 119), decreto seu perdimento em favor da União. Preceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas, cobrando-se o envio do comprovante de depósito respectiva. Já a bolsa apreendida deverá ser encaminhada para destruição, tendo em vista que se encontra em péssimo estado de conservação (fls. 173/174).

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 11 de janeiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA